

1500263-21.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500263-21.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2033353/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 22835775 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 451/22/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 451/2022 - 1º Distrito

Policial de Mauá, 2033353 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATHEUS FILGUEIRAS DIAS e outro

Data da Audiência:

17/03/2022

Em 17 de março de 2022 às 16h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, os acusados e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho

Soffner. Presentes os réus Matheus Filgueiras Dias e João Victor da Silva, citados em audiência. Presente o Advogado, Dr. Evandro da Silva Marques (OAB/SP 167188). Presentes as testemunhas Marcelo Scorzelli e Tiago de Sousa Santos. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "MM. Juiz, Matheus Filgueiras Dias e João Victor da Silva, devidamente qualificados nos autos do processo em epigrafe, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, por seu advogado infra assinado, apresentar DEFESA PRÉVIA nos termos da Lei, requerendo desde já a improcedência da acusação que lhes é feita. Em que pese as acusações formuladas na denúncia, tendo em vista a inexistência para a condenação dos acusados, requer a absolvição. Requer por ultimo a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia. Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor dos acusados." A seguir, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi requerido nova conversa com os acusados antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foram interrogados os réus. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MATHEUS FILGUEIRAS DIAS, qualificado às fls. 27, e JOÃO VICTOR DA SILVA, qualificado às fls. 30, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 12h:00min, na Avenida Santa Catarina, nº 48, Vila Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, transportavam e traziam consigo, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 1.000 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 396,1g, e 50 invólucros de "MD", com peso líquido de 49,8g, drogas ilícita que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação de fls. 21/24, e laudo químicotoxicológico de fls. 208/210 (fls. 120/122). Foi convertida a prisão em flagrante dos acusados em preventiva (fls. 60/61). A denúncia foi oferecida (fls. 119). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 123/127 e 174). Os réus foram notificados (fls. 200 e 202), apresentaram defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi mantida (termo de audiência) e os réus foram citados (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Marcelo Scorzelli (gravação audiovisual) e Tiago de Sousa Santos (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório dos réus Matheus Filgueiras Dias (gravação audiovisual) e João Victor da Silva (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Scorzelli (fls. 4) e Tiago de Sousa Santos (fls. 5) e os réus Matheus Filgueiras Dias (fls. 6) e João Victor da Silva (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial fechado para o

início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa dos réus Matheus e João Victor, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 17/18). Laudo de constatação provisória (fls. 21/24). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 208/210). Folha de antecedentes (réu Matheus - fls. 38/39 - e réu João Victor - fls. 43/44) e certidão (réu Matheus - fls. 41/42 - e réu João Victor - fls.

46/47). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 21/24), exame químico toxicológico definitivo (fls. 208/210) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Marcelo Scorzelli disse que: a) me recordo da ocorrência do dia 04 de fevereiro de 2022, envolvendo os acusados; b) estávamos em patrulhamento com vistas a roubo de carga no complexo Rodoanel e passou um veículo meio que em alta velocidade e o passageiro se encolheu no banco, foi o que motivou a abordagem; b) abordamos eles e nada foi localizado em busca pessoal; c) no compartimento do estepe foram encontradas as drogas pela testemunha Tiago; d) não havia compartimento secreto, mas estava em uma sacola no compartimento do estepe; e) haviam 1000 comprimidos de ecstasy e uma pedra derivada do ecstasy chamada de MD; f) eles informaram que pediram o veículo emprestado e na parte da manhã foram até a Praia Grande adquiriram as drogas, que seriam entregues em Santo André, mas não disseram de quem adquiriram ou para quem entregaria, e receberiam uma quantia; g) não os conhecia de outras ocorrências; h) eles disseram que receberiam R\$ 350,00, somente me falaram sobre este valor, acredito que seria para cada um (gravação audiovisual e fls. 4). A testemunha Tiago de Sousa Santos, sob o crivo do contraditório, disse que: a) em recordo da ocorrência do dia 04 de fevereiro de 2022, envolvendo os réus; b) estávamos em patrulhamento pela Avenida Oscar Nieneyer onde passou um veículo em alta velocidade e o passageiro tentou se esconder; c) conseguimos aborda-los na Rua Santa Catarina; d) em busca pessoal, não encontraríamos nada, mas em vistoria veicular, no porta malas, no compartimento do estepe havia uma sacola, eu a retire e tinham as substâncias entorpecentes, que aparentava serem comprimidos de ecstasy, aproximadamente 1000 comprimidos; e) havia MD e uns cristais; f) a sacola preta estava ao lado do estepe; g) eles disseram que tinham buscado as drogas na Praia Grande e receberiam R\$ 350,00 e já teriam feito isso outras vezes; h) não conhecia os réus; i) eles não disseram de quem adquiriram as drogas e para quem as entregaria; j) o meu parceiro participou da confissão informal dos réus; k) eles disseram que estaria levando as drogas para Santo André (gravação audiovisual e fls. 5). Ao ser interrogado judicialmente, o réu Matheus Filgueiras Dias disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) nós estávamos efetuando a entrega das drogas para um amigo nosso; b) nós adquirimos a droga próximo ao Extra na Praia Grande; c) esse amigo se chama Luís, mas não sei o nome completo, ele mora na Rua Boa Visão, próximo ao Assai da Vila Lusita, em Santo André, mas não sei o número; d) nós pegamos a droga na Praia Grande de uma pessoa que foi alinhada pelo Luís e não sei o nome, somente fomos pegar as drogas para o Luís; e) eram comprimidos de ecstasy e um porção de MD; f) ganharíamos R\$ 350,00 cada um; g) não conhecíamos os policiais; h) as drogas estavam no porta malas, próximo ao estepe; i) estou arrependido; j) eu era o motorista do veículo e o João era o passageiro; k) o processo de roubo na Vara da Infância eu participei com o João (gravação audiovisual e fls. 6). Por fim, o réu João Victor da Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que:

a) os fatos são verdadeiros; b) fomos buscar as drogas na Praia Grande; c) adquirimos as drogas de uma pessoa que eu não conhecia, porque não fui eu quem articulei; d) iríamos levar as drogas para Santo André, no bairro próximo da Vila Lusita, e não quero falar para quem iria entregar, porque tenho medo; e) ganharíamos R\$ 700,00, R\$ 350,00 para cada; f) as drogas estavam no porta malas, no compartimento de estepe, não havia compartimento secreto; g) as drogas eram ecstasy e MD, comprimidos; h) eu era o passageiro do veículo e o Matheus estava no motorista; i) estou arrependido (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo

auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 21/24), exame químico toxicológico definitivo (fls. 208/210), como também pelos depoimentos das testemunhas Marcelo Scorzelli (gravação audiovisual e fls. 4) e Tiago de Sousa Santos (gravação audiovisual e fls. 5), e pelas confissões dos réus Matheus Filgueiras Dias (gravação audiovisual e fls. 6) o réu João Victor da Silva (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando passou por eles o veículo Honda City, placas EVD5750, em alta velocidade, e o passageiro se encolheu no banco, o que motivou a abordagem deles. O réu Matheus era o condutor do mencionado veículo e o réu João Victor o seu passageiro. Em revista pessoal nada foi localizado com eles, contudo em uma sacola preta, que estava dentro do porta-malas, foram apreendidos 1.000 porções de ecstasy, pesando 396,1g, e 50 porções de "MD", pesando 49,8g. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação dos réus Matheus Filgueiras Dias e João Victor da Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. a) Em relação ao réu Matheus: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (1.000 porções de ecstasy, pesando 396,1g, e 50 porções de "MD", pesando 49,8g - fls. 17/18, 21/24 e 208/210) permitem aumentar a pena em 1/2, passando para 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa, como também as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 38/39 e 41/42). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. No entanto, reduzo a pena do réu em 1/3 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), sendo 1/6 por ele ter confessado o crime (gravação audiovisual) e 1/6 por ele ser menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 8 e 27), passando a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque a depender da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, a ser verificada no caso concreto, indubitavelmente se inferiria a dedicação à atividade criminosa, porque nenhuma organização criminosa confere certa quantidade de drogas, neste caso 1.000 comprimidos de ecstasy, pesando 396,1g, e 50 porções de "MD", pesando 49,8g (fls. 17/18, 21/24 e 208/210), a qualquer pessoa, a não ser que tenha plena confiança nesta pessoa, de onde se inferiria a dedicação à atividade criminosa, já que esta pessoa estaria inserida em algum ponto da cadeia do tráfico de drogas. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.0540 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. No caso do tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 determina que o juiz "na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" - (grifei). Ou seja, a fixação da pena compreende a dosimetria e o regime inicial de cumprimento, tanto que o legislador ressaltou que a natureza e a quantidade das drogas e a conduta social preponderam sobre o artigo 59 do Código de Processo Penal, e este artigo (59

do Código de Processo Penal) deve ser considerado na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, conforme prevê o artigo 33, § 3º, do Código de Processo Penal. Desta maneira, fixo o regime inicial de cumprimento da pena fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, a despeito de a pena ser inferior a quatro anos e os réus não serem reincidentes (fls. 38/39 e 41/42), a natureza e quantidade das drogas apreendidas (1.000 porções de ecstasy, pesando 396,1g, e 50 porções de "MD", pesando 49,8g – fls. 17/18, 21/24 e 208/210), preponderam sobre o artigo 59 do Código Penal, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, e o artigo 59 do Código Penal deve ser levado em consideração na dosimetria da pena, segundo preceitua o artigo 33, § 3º, do Código Penal. Neste sentido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENA E RECUSA DE ENVIO À PGJ. RECUSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO PARQUET. ANUÊNCIA DO MAGISTRADO. PROPOSTA DE REVISÃO REQUERIDA A DESTEMPO PELA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe de 20/2/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 27/3/2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra CARMEM LÚCIA, DJe de 3/6/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/11/2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 17/9/2019 e HC 174184-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro FÉLIX FISCHER, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe de 3/4/2018. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 4. Conforme o acórdão ora impugnado, o requerimento de revisão do não oferecimento de proposta do ANPP, para fins de análise do órgão superior do Ministério Público local, ocorreu a destempe pela defesa, deixando que a instrução criminal fluísse regularmente. 5. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 6. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (62 porções de cocaína, contendo 55,63g; 04 pedras de crack, contendo 0,41g; e 63 porções de "maconha", contendo 132,64g) , utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos. 7. Habeas corpus não conhecido." -

(grifei). (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte a quo afastou a aplicou a minorante considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a quantidade e variedade das drogas apreendidas. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas - 18,7g de cocaína e 348,5g de Cannabis sativa - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Tendo a reprimenda ultrapassado os 4 anos de prisão, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial semiaberto, segundo a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido." - (grifei). (AgRg no AREsp 1671723/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. III - Ademais, a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta requer fundamentação específica, baseada em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. IV - No caso, aplicada a pena de 2 anos de reclusão, entendo que deve ser estabelecido o regime inicial intermediário, nos termos do art.33, § 3º, do Código Penal, e do art.42 da Lei de Drogas. A quantidade e variedade dos entorpecentes podem ser utilizadas como fundamento a ensejar a aplicação do regime mais danoso, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/06. V - O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC n. 97.256/RS, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, passou a admitir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. VI - Na hipótese em análise, a quantidade e diversidade das drogas apreendidas (195,6g maconha, 63,9g de cocaína, 17,1g de crack e mais 118g de cocaína) não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da benesse em tela. Habeas corpus não conhecido. Ordem de ofício apenas para fixar o regime semiaberto para resgate da reprimenda, mantido os demais termos da condenação." - (grifei). (HC 581.356/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020). "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MODO ADEQUADO. AFASTAR CARÁTER HEDIONDO. PLEITO PREJUDICADO. DETRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Concluído pelas instâncias antecedentes, com fulcro nos elementos constantes dos autos e no fato de registrar atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, que o agravante se dedica ao tráfico de drogas, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. 4. Embora o agente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento das sanções impostas, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza de entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 5. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal). 6. Fica prejudicado o pleito de afastamento do caráter hediondo do delito, pelo não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado. 7. Noticiado o trânsito em julgado da ação penal, caberá ao Juízo de execução penal averiguar a possibilidade de estabelecimento de regime mais brando diante do desconto do período em que o agravante permaneceu preso preventivamente. 8. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 573.149/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) - (grifei). Não substituo a pena do réu, porque, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal, não é socialmente recomendável, pela natureza e quantidade das drogas (1.000 comprimidos de ecstasy, pesando 396,1g, e 50 porções de "MD", pesando 49,8g - fls. 17/18, 21/24 e 208/210), fato concreto que impede a substituição. Em relação ao réu João Victor: Pelos mesmos motivos da fundamentação da pena do réu Marcelo (item a - mesma quantidade e natureza das drogas - 1.000 porções de ecstasy, pesando 396,1g, e 50 porções de "MD", pesando 49,8g - fls. 17/18, 21/24 e 208/210 - primariedade - fls. 43/44 e 46/47 - confissão - gravação audiovisual - e menoridade - fls. 8 e 30), fixo a sua pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, no regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (réu Matheus - fls. 28 - e réu João Victor - fls. 31). O telefone celular apreendido (fls. 17/18), foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, porque ele estava sendo utilizado para comunicação dos traficantes (no caso do telefone celular) - (fls. 8/12, 17/18 e 21/24), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre ele e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Contudo, se se verificar que o valor é irrisório, determino que ele seja destruído, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei n.º 11.343/2006. Caso o contrário oficie-se ao FUNAD para que ele se aposse do bem. Com relação ao veículo apreendido, apesar de ele ter sido utilizado para o transporte das drogas, restituo-o ao terceiro de boa-fé, que é a requerente Zuleika Franco Rodrigues (fls. 1/18 do processo nº 1104-84.2022.8.26.0348 em apenso). Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em

julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (17/18, 21/24 e 208/210).
III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO os réus MATHEUS FILGUEIRAS DIAS (R.G. nº 54.720.466-SP

- filho de Janilson Filgueiras Dias e Danielle Nunes Agripino - fls. 6 e 27) e JOÃO VICTOR DA SILVA (R.G. nº 63.156.624-SP - filho de Carla Cristina Xavier da Silva - fls. 7 e 30), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a, respectivamente, 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 166 dias-multa, além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo, para cada um dos réus. Nego aos réus o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, os réus aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 60/61). Os réus arcarão com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido, se o valor for irrisório, ou oficie-se ao FUNAD para que o bem lhe seja entregue; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se os nomes dos réus no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Ministério Público, pela Defesa e pelos réus foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo os recursos requeridos pelo Ministério Público e pela Defesa. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas à Defesa para apresentação de contrarrazões e razões. Após vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Saem os presentes intimados." NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.